

1501691-21.2021.8.26.0363

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Raquel Campos Pinto Tilkian Neves

Comarca: Mogi-Mirim

Foro: Foro de Mogi Mirim

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 14/03/2022

... - Admissibilidade Nos casos de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei n. 11.343/06) é perfeitamente admissível a elevação da pena-base com base na quantidade e variedade mais nociva do tóxico apreendido, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos. Cálculo da Pena - Tráfico de entorpecentes - Agente reincidente - Inaplicabilidade da redução da pena prevista no art. 33, § 4º, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Mirim

Foro de Mogi Mirim

4ª Vara

Rua Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, Saúde - CEP 13800-221, Fone:

(19)3862-1407, Mogi Mirim-SP - E-mail: mojimirim4@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1501691-21.2021.8.26.0363

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ OTHAVIO CARLOS

Data da Audiência:

14/03/2022

Aos 14 de março de 2022 às 14:00 horas, em razão da pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum, conforme recentes determinações da Presidência desta Egrégia Corte, nos termos Comunicado CG nº 284/2020, excepcionalmente, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, sob a presidência da MM. Juíza de Direito da 4ª Vara da Comarca de Mogi Mirim, Dra. Maria Raquel Campos Pinto Tilkian Neves, comigo Escrevente ao final nomeada, regularmente conectado à sala virtual, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Aberta, com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão das seguintes partes: o DD. Promotor de Justiça Dr. Gaspar Pereira da Silva Junior, o acusado Luiz Othavio Carlos e seu advogado Dr. Gustavo Antonio Tavares do Amaral, e as testemunhas GM Marcelo Pereira Da Silva, GM Pedro Felipe Delatorre Mosca e Ana Amélia da Silva Bezerra. Certifico e dou fé que eu escrevente de sala abaixo assinada realizei a qualificação das partes registrando em gravação separada seus dados de identificação. INICIADOS OS TRABALHOS, com as formalidades legais, o réu pôde conversar reservadamente com seu advogado antes do início da solenidade. Procedeu-se ao início da audiência virtual com gravação através do Microsoft Teams, iniciando a coleta dos depoimentos das testemunhas GM Marcelo e GM Pedro, sendo estas adicionadas uma a uma, a partir do lobby, à audiência virtual. Após a testemunha Ana Amélia, que estava no escritório do patrono do réu, foi admitida à sala do patrono e prestou seu depoimento. A

qualificação da testemunha Ana Amélia foi feita pela MM. Juíza antes de sua inquirição, conforme consta na gravação. Ao final o réu foi interrogado. Não foram requeridas demais diligências, e deu-se por encerrada a instrução. Após, o Ministério Público e a defesa apresentaram alegações finais orais. Concluídos os atos acima a gravação foi encerrada. As inquirições das testemunhas, o interrogatório do réu e os debates orais foram realizadas pelo sistema de gravação em mídia digital, nos termos das Lei nº 11.419/06 e nº 11.719/08, e item 77, Capítulo II, das NGSCJ e Provimento CG nº 08/2011. Fica consignado que as partes poderão ter contato com o registro da gravação, sendo desnecessária a transcrição, de acordo com o art. 2º da Res. 105/2010 do CNJ. Observa-se ainda que nos termos do Comunicado CG nº 961/10, publicado no DJE de 11, 12 e 13/05/2010, foi revogada a recomendação contida no Comunicado CG nº 381/09, que indicava a necessidade de ser realizada a transcrição da prova assim que houvesse recurso da sentença. A presente gravação serve como prova em processos judiciais e poderá ser visualizada no Portal e-SAJ do Tribunal de Justiça de São Paulo junto a este termo de audiência. Pela MM. Juíza foi proferida a seguinte sentença: Vistos. LUIZ OTHÁVIO CARLOS, qualificado nos autos às fls. 07, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso nas penas do artigo 33, caput, c.c. art. 40 inciso III, ambos da Lei 11.343/06, porque no dia 22 de novembro de 2021, no período da manhã, à Rua Lázaro Franco de Moraes, 181, nas imediações dos estabelecimentos de ensino EMEB Vereadora Terezinha da Silva e Aninha Lar Infantil, nesta comarca e cidade Mogi Mirim, trazia consigo, para fins de tráfico, 192 porções contendo 1.560 gramas de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Narra a peça acusatória que os guardas municipais realizavam fiscalização de rotina pelo local quando avistaram o acusado saindo de casa com uma mochila, sendo que ao ver a guarnição, jogou a mochila ao chão e voltou correndo para dentro do imóvel. Consta ainda que os guardas abordaram o acusado e encontraram, dentro da mochila a droga apreendida, uma faca, uma tesoura e três balanças de precisão, sendo que ao ser questionado, o acusado confessou informalmente que a droga era destinada ao tráfico. A denúncia foi recebida em 24 de novembro de 2021 (fls. 54/56). Citado (fls. 95), o réu ofereceu defesa preliminar à fl. 67 por advogado constituído. Não identificadas hipóteses de absolvição sumária, foi mantido o recebimento da denúncia, designando-se audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 96/98). Durante a instrução foram inquiridas duas testemunhas arroladas pelas partes e, ao final, o réu foi interrogado. Em alegações finais, o Representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal com a condenação do réu pela prática do crime de tráfico de entorpecentes nos exatos termos da denúncia, vez que autoria e materialidade restaram comprovadas. A defesa do acusado, por sua vez, pugnou por sua absolvição, sustentando que o conjunto probatório é frágil para ensejar um decreto condenatório. É O RELATÓRIO. DECIDO. A pretensão punitiva estatal é procedente. A materialidade dos fatos está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito de fl. 04/05, pelo boletim de ocorrência de fls. 09/11, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 18/19, pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 20/21, pelas fotos de fls. 32/34, pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 71/73, pelos laudos de objetos fls. 74/76, 81/83, 90/92, pelo laudo pericial de local às fls. 84/89, bem como pela prova oral produzida em juízo e durante a lavratura do flagrante. A autoria, por seu turno, que já se revelava durante a instrução do inquérito policial, também restou confirmada após a colheita da prova oral sob o crivo do contraditório. A testemunha e guarda municipal Pedro Felipe Delatorre Mosca relatou que estava em patrulhamento quando avistou o acusado saindo da sua residência com uma mochila, sendo que ao ver a viatura, demonstrou nervosismo, dispensou a mochila ao solo e correu para dentro da casa. Contou que em razão da atitude suspeita, ele e seu colega decidiram pela abordagem do acusado. Narrou que ele perseguiu o acusado dentro da residência e seu colega verificou a mochila em questão, encontrando maconha e balanças de precisão. Relatou que ao ser questionado o acusado confessou a propriedade da droga. A testemunha e guarda municipal Marcelo Pereira da Silva relatou que estava em patrulhamento pelo local dos fatos, quando ele e seu colega avistaram o acusado saindo da sua residência com uma mochila. Narrou que assim que ele viu a viatura,

ficou assustado e jogou a mochila no chão, correndo para dentro da casa. Contou que em razão da atitude suspeita, seu colega perseguiu o acusado dentro da residência enquanto ele verificou a mochila, encontrando nela 186 porções de maconha individualizadas, 2 tijolos e uma porção grande embalada, além de balanças de precisão, uma faca e uma tesoura. Relatou que ao ser questionado o acusado confessou a propriedade da droga. Já o conhecia dos meios policiais, em virtude de estar ele envolvido no tráfico de drogas no bairro em que ele mora. A testemunha arrolada pela defesa Ana Amélia da Silva Bezerra afirmou que presenciou a chegada da polícia ao local e que o réu não estava na rua nem havia ali sua mochila. Aduziu que os guardas saíram com o réu de dentro de casa. Em seu interrogatório o réu negou a prática delitiva. Alegou que estava dormindo quando os policiais entraram na residência. Esclareceu que a porta que dá acesso ao corredor não tranca e por isso eles entraram no local livremente. Negou a propriedade da droga e da mochila. Negou que estivesse na rua e não sabe dizer por que os policiais iriam querer incriminá-lo. Como se pode ver, o réu negou a prática do delito, porém sua versão restou isolada ante o conjunto probatório. Os guardas que realizaram a diligência puderam avistar pessoalmente o acusado dispensando ao solo a mochila que continha as drogas e tentando sair do local e se escondendo dentro do imóvel. Note-se que foi a própria atitude do acusado que motivou a abordagem. Cumpre frisar que as testemunhas são agentes da lei, não havendo motivo específico para se duvidar de sua credibilidade, até porque não foi apresentada razão plausível para se desacreditar seus depoimentos, de forma a explicar a razão pela qual estes mentiriam em juízo com o fim de incriminar inocentes. Na atuação do ofício como agentes da lei deve-se presumir, ao menos até prova em contrário (que não existe no caso dos autos,) que as testemunhas agiram dentro de seus direitos e deveres. Em verdade, os relatos dos guardas responsáveis pelo flagrante tornam certa a participação do acusado no crime a ele imputado. Não bastasse, o contexto flagrancial permite a certeza visual do crime, em razão da direta constatação da ação, valendo, relembrar, que o flagrante delito conduz à irrefutabilidade das provas sobre a autoria, permitindo a adequada incidência da justiça repressiva sobre o transgressor. Disto se depreende a necessidade de se conceder credibilidade à prova oral em análise. Nesse sentido: APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas privilegiado circunstanciado – Artigo 33, §4º, c. c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006 – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavra dos policiais – Validade – Precedentes – Policiais que não tinham motivo algum para falsamente incriminar um desconhecido inocente – Insubsistente alegação de ausência de provas ou a desclassificação para uso – Condenação mantida – Pena – Dosimetria – Reprimenda aplicada de forma exacerbada – Necessidade de afastamento da causa de aumento relativa à proximidade de estabelecimento educacional – Tal circunstância não foi descrita na exordial – Ausência de correlação entre acusação e sentença – Ademais, não restou demonstrado nos autos a proximidade com estabelecimento de ensino -- Regime inicial fechado – Adequado ao caso concreto – Diante do quantum de pena, era mesma inviável a substituição – Gratuidade

da Justiça – Necessidade – Deve-se presumir verdadeira a alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1500200-46.2019.8.26.0622; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapeva - 2ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 30/07/2020; Data de Registro: 30/07/2020) Repiso, ainda, que os guardas municipais, policiais militares e policiais civis, como servidores públicos que são, gozam de credibilidade, sendo seus testemunhos plenamente válidos, até porque inexistem impedimentos de ordem moral para afastá-los, como já decido pelo Superior Tribunal de Justiça: “Cálculo da Pena – Tráfico de Entorpecentes – Agente flagrado tendo em depósito e guardando 33,67 gramas cocaína sob a forma de "crack" (03 pedras), 101,11 gramas de cocaína (82 porções) e 607,01 gramas de maconha (01 "tijolo" e 02 "tabletes") – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples

condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. Exacerbação da pena-base seguindo os critérios norteadores previstos no art. 42 da Lei n. 11.343/06, em razão da quantidade e a variedade do entorpecente apreendido – Admissibilidade Nos casos de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei n. 11.343/06) é perfeitamente admissível a elevação da pena-base com base na quantidade e variedade mais nociva do tóxico apreendido, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos. Cálculo da Pena – Tráfico de entorpecentes – Agente reincidente – Inaplicabilidade da redução da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 O fato de o agente ser reincidente afasta a possibilidade de incidência da redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, em razão de expressa vedação legal neste sentido, uma vez que, dentre os requisitos previstos para referido benefício, consta a primariedade do agente. (TJSP; Apelação Criminal 1500212-53.2020.8.26.0613; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Casa Branca - 1ª Vara; Data do Julgamento: 30/04/2021; Data de Registro: 30/04/2021) Importante dizer que a configuração do tráfico de entorpecentes prescinde da demonstração de atos de mercancia, bastando tão somente a constatação de uma das múltiplas ações previstas no tipo penal, intentadas com o escopo de trazer consigo para venda e entrega ao consumo alheio, o que restou fartamente demonstrado no caso. “Tráfico de entorpecentes – Agente flagrado trazendo consigo e guardando 31,4 gramas de maconha, 1,6 gramas de cocaína sob a forma de “crack” e 0,9 gramas de cocaína em pó – (...) Tráfico de entorpecentes – Agente que traz consigo substância estupefaciente e é flagrado na prática de oferta gratuita ou de venda – Caracterização Basta à realização do tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 o fato do agente ser flagrado “trazendo consigo” substância entorpecente, com o intuito de tráfico. Conquanto a tipicidade dessa conduta prescinda da demonstração da prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente a terceiro, sua subsunção à descrição legal tornar-se-á ainda mais evidente na hipótese de haver flagrância também dessa circunstância. Tráfico de entorpecentes – Diligência na qual policiais solicitam entorpecentes aos suspeitos de tráfico – Caracterização e consumação prévias do crime em razão de conduta anterior do agente consistente em “manter”, “guardar” ou “ter em depósito” substância estupefaciente (...). (TJSP; Apelação Criminal 0028921-57.2016.8.26.0050; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 14ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/04/2020; Data de Registro: 13/04/2020) (grifo meu) Repiso, o acusado foi visto deixando sua residência enquanto carregava a mochila com os objetos em questão, ademais, a atitude de se assustar com a viatura, dispensar a mochila e fugir para dentro do imóvel, apenas coloca em evidência o seu protagonismo no crime em tela. Saliente-se que a testemunha de defesa não soube precisar exatamente o local em que se encontrava e que a permitiu visualizar o ingresso e a saída dos guardas com o réu de dentro da casa. Assim, reputo que este relato não é suficiente para esmorecer a certeza que se extrai do depoimento dos guardas municipais. Por fim, há ainda que se analisar a questão do local em que o crime ocorreu, uma vez que, ao analisar o laudo de local acostado às fls. 84/89, constata-se que a prática criminosa se deu próximo a escolas infantis. Tais locais são de intenso de trânsito de crianças e jovens, o que agrava sobremaneira a conduta do acusado, configurando a causa de aumento do artigo 40, III da Lei 11.343/06. A lei pune com maior severidade o comércio ilícito em determinadas regiões pelo perigo em abstrato que ele enseja, o que significa que é irrelevante a ausência de notícia sobre a movimentação de populares ou de expediente nos sítios escudados, já que é despidiêda a demonstração de que os acusados tinham os frequentadores de tais locais como público-alvo do ilícito comércio. Como se sabe, o tráfico de drogas é crime habitual, aquele que se insere na rotina e no modo de vida do criminoso configurando a periculosidade que a legislação pretendeu punir mais gravemente. Somando-se tal contexto às demais provas reunidas, impõe-se o édito condenatório calcado nas sinceras provas coligidas que demonstram seguramente

sua atuação na prática do tráfico de drogas. Passo, então, à dosimetria das penas. Observando-se os elementos dos autos, bem como aqueles norteadores previstos nos artigos 59 e 60, do Código Penal, e no artigo 42, da Lei nº 11.343/06, verifico que o réu não ostenta mau antecedente, porém a grande quantidade de droga apreendida justifica a fixação da pena base acima de seu mínimo legal, ou seja, 05 anos e 03 meses de reclusão e ao pagamento de 530 dias-multa. Reconheço a atenuante da menoridade relativa, vez que o acusado possuía 20 anos à época do delito, de forma que reconduzo a pena ao seu mínimo legal, ou seja, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na terceira fase, aplico a causa de aumento prevista pelo artigo 40, inciso III da Lei 11.343/06, por tanto, aumento-lhe a pena em 1/6 chegando a 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Ainda na terceira fase, considerando-se que o réu é primário, que ostenta bons antecedentes e que não há provas ou indícios de que ela integre associação criminosa, e de outro lado grande quantidade de droga apreendida, aplico o disposto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, e reduzo a pena de metade, atingindo o montante de 02 anos e 11 meses de reclusão e ao pagamento de 291 dias-multa. Fixo cada dia-multa no mínimo legal, por falta de maiores elementos que indiquem ser o acusado portador de situação econômica favorável. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e o faço para condenar LUIZ OTHÁVIO CARLOS, qualificado nos autos às fls. 17/18, à pena de 02 anos e 11 meses de reclusão e ao pagamento de 291 no valor unitário mínimo legal previsto no art. 43 da Lei 11.343/06, por incursão no artigo 33, caput da Lei n. 11.343/06 c.c. artigo 40, inciso III da mesma lei. Em obediência ao quanto determinado no HC nº 596.603-SP, do C. STJ, fixo o regime inicial aberto para cumprimento de pena e substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de um salário mínimo, ambas a serem vertidas em favor de entidade a ser indicada pelo juízo da execução. Eventual detração da pena deverá ser valorada no juízo da execução penal. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO. Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade. Isento de custas por ser beneficiário da justiça gratuita. Publicada em audiência, saem os presente intimados. Cumpra-se. Pelo Ministério Público foi dito que não desejava recorrer. Pela MM. Juíza foi deliberado: Aguarde-se o prazo recursal obrigatório do Ministério Público. Saem os presente cientes e intimados. Resta consignado que foi permitida às partes a leitura deste termo que, após a manifestação de suas concordâncias quanto ao seu teor, foi assinado pela MM. Juíza. Lido e achado conforme. Nada mais a ser tratado na referida audiência, foi determinado o encerramento deste termo, bem como o término desta videoconferência. Eu, (Tânia Barbeto Bovo, matrícula M367511), digitei.